

1500473-53.2022.8.26.0126

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... que meu marido esta envolvido no tráfico", por isso realizam tais abordagens. "ele não tem envolvimento no tráfico". Ele apenas tem antecessores criminais por pratica de furto. Informa que no ano de 2006 teve envolvimento no trafico e que ficou preso por um ano, e após nunca mais teve qualquer envolvimento em fatos policiais semelhantes. Alega que não conhece a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba - Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, Caraguatatuba - SP - cep 11660-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500473-53.2022.8.26.0126 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500473-53.2022.8.26.0126

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADAUARI DA SILVA JÚNIOR e outro

Vistos.

ADAUARI DA SILVA JUNIOR e ALESSANDRA APARECIDA DIAS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei nº. 11.343/2006, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal. Segundo narra a denúncia e o que consta dos inclusos autos de inquérito policial que em data incerta, porém, anteriormente ao dia 05 de maio de 2022, os acusados associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o delito de tráfico de drogas.

Consta também que, no dia 05 de maio de 2022, às 16:20 horas, na Travessa Engenho Velho, 1, área de mata, Sumaré, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba, ADAURI DA SILVA JUNIOR trazia consigo, para fins de tráfico de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 20 (vinte) porções de cocaína, bem como guardava e tinha em depósito, 240 (duzentos e quarenta) porções de maconha e 998 (novecentos e noventa e oito) papérolas de cocaína. Sua esposa, ALESSANDRA APARECIDA DIAS, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 240 (duzentos e quarenta) porções de maconha e 998 (novecentos e noventa e oito) papérolas de cocaína.

Ainda, em data incerta, porém, anteriormente ao dia 05 de maio de 2022, ADAURI DA SILVA JUNIOR e ALESSANDRA APARECIDA DIAS corromperam a menor H. A. G. (DN: 14/08/2006 - quinze anos de idade), com ela praticando as infrações anteriormente descritas.

A denúncia foi recebida em 11 de maio de 2022 (fls. 153/154). Os réus foram citados (fls. 165 e 167), e apresentaram resposta à acusação (fls. 223/224).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas em comum, bem como foi realizado o interrogatório dos réus, tudo por intermédio de sistema audiovisual,

constando as respectivas gravações armazenadas na mídia.

Encerrada a instrução criminal, na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição dos réus.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é PARCIALMENTE PROCEDENTE. A ação é PROCEDENTE em relação ao delito de tráfico e IMPROCEDENTE no que toca ao delito de associação ao tráfico e corrupção de menores. Senão vejamos.

Em relação ao delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, a materialidade delitiva é comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 5/7) e demais peças que o acompanham, boletim de ocorrência (fls. 08/12), auto de exibição e apreensão (fls. 32/33), auto de constatação preliminar (fl. 31) e laudos periciais (fls. 170/172 e 319/324) que confirmam a natureza das substâncias apreendidas e demais provas produzidas nos autos.

A autoria delitiva, também, restou demonstrada e caracterizada nos autos.

A testemunha e policial militar JOSÉ AUGUSTO FREITAS DOS SANTOS, na delegacia, disse que, juntamente com seu colega de farda, realizavam trabalho ostensivo preventivo e que na data dos fatos, visando coibir o tráfico de entorpecentes na região, juntamente com outras equipes policiais (Força Tática), realizaram uma incursão pela Travessa Engenho Velho, no bairro Sumaré, local já bastante conhecido nos meios policiais como “ponto de venda de drogas”. No local, depararam a adolescente H.A.G com uma sacola contendo 60 embalagens a vácuo com cocaína, 76 pedras de crack, 40 buchas de maconha, 12 pinos com um substância esverdeada assemelhada a maconha, todas embaladas, mormente semelhantes as que se encontram prontas para a venda, e a quantia de R\$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais). Consta que junto com a adolescente foi abordado Everton, sendo localizado em sua posse 01 pedra de crack, o qual informou que é usuário e havia acabado de comprar com a adolescente H.A.G aquele entorpecente. Durante a abordagem, H.A.G informou ao depoente que o responsável pelo abastecimento das drogas bem como da recolha do dinheiro arrecadado com a venda dos entorpecentes era a pessoa de ADAURI, indicando a residência do mesmo, sendo na Travessa Benedito Alves, Nº 90, casa 2, bem próximo do local da abordagem. Diante dos fatos o depoente e demais se deslocaram até esta residência, e que de frente a porta de entrada deste imóvel se depararam com ALESSANDRA, companheira de ADAURI. Informa que durante a abordagem, através da porta, já foi possível visualizar certa quantidade de entorpecentes dentro da residência. (Foi então iniciada a revista no imóvel, onde foi localizada uma grande quantidade de entorpecentes espalhados no chão do interior do imóvel, a saber: 240 buchas de maconha e 998 porções de cocaína embaladas a vácuo), todas embaladas prontas para a venda, sendo que tal substância se assemelham entre si, ou seja, as embalagens encontradas em poder da adolescente são semelhantes às embalagens encontradas na moradia do casal. Durante as diligências, ADAURI DA SILVA JUNIOR, que já é conhecido nos meios policiais, foi abordado retornando para sua residência, e em revista pessoal foi encontrado com ele a quantia de 20 porções de cocaína embaladas a vácuo, semelhante as que foram encontradas em sua residência e na sacola que estava com a adolescente, e que ao ser questionado, assumiu a propriedade dos entorpecentes. Diante dos fatos, os Policiais conduziram os envolvidos até a delegacia, juntamente com todos os entorpecentes, onde foi apresentada a ocorrência à Autoridade Policial para serem tomadas as devidas providências. Em juízo, prestou depoimento semelhante ao da fase policial. Esclareceu que ALESSANDRA negou a prática do crime a todo momento. A casa é muito próxima da rua, possibilitando a visualização dos entorpecentes. Segundo a adolescente, o réu ADAURI havia acabado de pegar dinheiro com ela, proveniente do tráfico de drogas. O réu ADAURI é conhecido pela prática do tráfico de drogas no local. O réu reside próximo ao ponto de venda de entorpecentes. Não foi autorizado a entrar na residência. Os entorpecentes estavam no chão da residência, que possui poucos cômodos.

A testemunha e policial AUGUSTO OTÁVIO GAMA DE OLIVEIRA, que também participou dos fatos narrados da denúncia, na delegacia e em Juízo, prestou depoimento, também de maneira firme, corroborando a versão narrada por seu colega. Em juízo, prestou depoimento semelhante ao da fase policial. Esclareceu que ADAURI era conhecido por praticar tráfico de drogas no local. A porta da casa estava entreaberta e possibilitava a visualização das drogas. Alega que não obteve autorização para entrar na residência. Era uma casa bagunçada, mas com características de residência. Na residência havia poucos cômodos, aparentemente uma sala/quarto e dois banheiros. O réu ADAURI teria assumido a propriedade das drogas, alegando que sua esposa era apenas uma "olheira". O réu teria citado o nome de Genival, vulgo "Japa", que seria responsável pela biqueira, tendo o réu lhe pedido para não dar esses detalhes em audiência, pois o "Gravata" repassaria as informações ao PCC. Em seu interrogatório policial o réu ADAURI DA SILVA JÚNIOR, na delegacia, negou os fatos. Disse que os policiais estavam mentindo e que ali chegaram a sua casa com a alegação de que "gordo", pessoa que havia sido presa na terça feira passada teria dito que a casa do interrogado se guarda drogas, mas isso tudo é mentira. Os policiais não aceitaram tal alegação e resolveram trazer preso. Nega qualquer envolvimento nestes fatos. Alega que hoje, do mesmo jeito lá chegaram e passaram a revistar, mas nada encontraram e levaram eu e minha esposa para a viatura e após trouxeram para a delegacia. Não conhece os demais envolvidos. Em juízo, confessa a autoria delitiva. Alega que sua mulher não está envolvida no crime. Alega que praticou o crime porque precisava de dinheiro. Não conhece a adolescente e não pegou dinheiro com ela. Os entorpecentes estavam em local fácil, porque logo a pegaria para entregar. A abordagem ocorreu enquanto ele foi ao mercado. Traficou drogas apenas naquele dia. Viu as viaturas em sua casa e foi até o local. Já tinha sido abordado por um dos policiais, que alegou ter uma denúncia contra ele, de que ele estava praticando o tráfico de drogas. Entretanto alega que essa abordagem foi feita a sua esposa, e que não estava no local. Alega que não reconheceu a propriedade das drogas na delegacia. Esclarece que deixou a droga no chão (no fácil).

Em seu interrogatório policial a corré ALESSANDRA APARECIDA DIAS, na delegacia, declarou que quando de sua abordagem foi coagida pelos militares os quais informaram que poderiam agredi-la. Narra que não é a primeira vez que sobre tais abordagens policiais e que a última abordagem há sete dias. Constantemente entrem em sua residência sem autorização da indiciada. Alega que na data de hoje, estava no interior da casa e novamente sofreu abordagem e foram todos entrando ali. Nada foi encontrado em seu poder, bem como nada em sua moradia foi encontrada. Salienta que quando da chegada dos policiais seus filhos menores estavam no portão de sua casa, brincando com outras crianças." Eles acham que meu marido esta envolvido no tráfico", por isso realizam tais abordagens. "ele não tem envolvimento no tráfico". Ele apenas tem antecessores criminais por pratica de furto. Informa que no ano de 2006 teve envolvimento no trafico e que ficou preso por um ano, e após nunca mais teve qualquer envolvimento em fatos policiais semelhantes. Alega que não conhece a adolescente; "eu não a conheço". Indagada sobre quem seria Everton, informou: "não sei que seria Everton". Em juízo, nega a autoria delitiva. Afirma que estava chegando em casa quando foi abordada pelos policiais. Não conhece a adolescente. Convive com o réu há cerca de um ano e cinco meses. Nesse período o réu não foi abordado por policiais, pois sempre viajava a trabalho. Alega que os policiais nunca haviam estado em sua residência antes. Não autorizou a entrada dos policiais na residência. Os policiais entraram e começaram a revirar a casa, à procura de drogas. Não viu a adolescente. Alega que os policiais não disseram o motivo pelo qual a levariam para a delegacia, tendo dito que ela retornaria à sua casa depois. Inicialmente, afasto a alegação de inobservância da inviolabilidade de domicílio dos acusados.

Como se sabe, em situações de flagrante delito, como ocorre no caso de armazenamento de entorpecentes em residência, tendo em vista que o tráfico é crime permanente, o ingresso das forças policiais no imóvel apenas será lícito se houver fundadas razões que corroborem, a priori, seu entendimento de que, no interior da residência pratica-se um crime.

Entendo que, no presente caso, estavam presentes as fundadas razões acima mencionadas, tendo em vista que, em todas as ocasiões em que ouvidos, os policiais militares, em uníssono, confirmaram que a adolescente H. A. G. indicou a residência dos acusados como ponto de fornecimento de entorpecentes. Chegando ao local, os policiais puderam visualizar, através da porta, certa quantidade de entorpecentes no interior do imóvel. Nesse ponto, ressalte-se que o réu ADAURI relata que deixou os entorpecentes em local de fácil visualização, corroborando o depoimento dos policiais. Sendo assim, a soma da atitude suspeita com a efetiva localização de entorpecentes em posse dos acusados, mesmo antes da entrada policial, constitui cenário fático excepcional, que corroborava as suspeitas dos agentes de segurança quanto à presença de ilícitos no interior da residência.

Ressalte-se que a jurisprudência entende ser viável a busca domiciliar em casos de crimes permanentes sem mácula ao princípio da inviolabilidade de domicílio, nesse sentido:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016);

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. EXCEÇÃO À INVIOABILIDADE DE DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) II - Segundo pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria. A certeza, a toda evidência, somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate. III- Segundo esta eg. Corte Superior, "dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n.

1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). IV - O col. STF, em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE n. 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016). V - Do contrário, devidamente analisado o pleito na origem, o eventual acolhimento da tese defensiva demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 130.337/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

Assim, pautado por tais entendimentos jurisprudenciais, afasto a tese de violação à inviolabilidade de domicílio, mormente levando-se em consideração que, de fato, os acusados estavam em posse de grande quantidade de entorpecentes no interior da residência vistoriada.

Superado tal ponto, passo ao mérito.

Como se vê, o conjunto probatório é suficiente para condenar os réus pelo crime de tráfico. Isto porque, as declarações dos policiais militares foram coesas desde a fase inquisitiva. Além disso, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, a dinâmica da abordagem, o local dos fatos, já conhecido como ponto de venda de drogas, as declarações da menor H. A. G. indicando os réus como responsáveis pela distribuição dos entorpecentes, bem como a quantidade de drogas localizada, demonstram a autoria delitiva.

Observa-se que os réus apresentam versões claramente dissonantes em diversos pontos. O réu ADAURI alega que os policiais foram à sua casa em data anterior e abordaram sua esposa. A ré ALESSANDRA, por sua vez, alega que os policiais nunca tinham ido à residência. O réu ARAURI afirma que deixou a droga "no fácil", em local de fácil localização, ao passo que a ré ALESSANDRA afirma que os policiais reviraram a residência para achar os entorpecentes.

A adolescente, ouvida pelo Juízo da Infância e da Juventude, admitiu a verdade dos fatos, o que corrobora a versão apresentada pelos policiais, de que ela teria indicado a residência do réu e afirmado que ele havia acabado de ir ao mercado (fato que também ficou demonstrado). Nesse ponto, a despeito do que a defesa pretende fazer crer, é insofismável a tese de que a adolescente e os réus não praticavam o tráfico de drogas juntos. Isso porque a versão dos policiais está amparada por todo o conjunto probatório sendo as alegações da defesa, além de divorciadas do conjunto probatório, absolutamente ilógicas.

No mais, a jurisprudência é pacífica acerca da desnecessidade que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida para a configuração da traficância. Assim "(...) a classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347).

Consigne-se, ainda, que a impugnação à valoração do depoimento dos policiais deve ser afastada, vez que inexistente qualquer elemento apto a sustentar a alegação de suspeição. Está pacificado na jurisprudência que a condição de policial seja militar ou civil, estadual, federal ou municipal, por si só, não invalida o seu testemunho, porquanto ele não está impedido de depor e se sujeita a compromisso como outra testemunha qualquer, litteris: Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (HC 146.381/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.06.10, DJe 09.08.10).

Registre-se que, além de não demonstrado o interesse dos policiais em prejudica-lo, o depoimento deles "podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte". (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).

No mesmo sentido: "Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal" (Superior Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Nota-se, portanto, que a traficância restou devidamente caracterizada, já que, conforme lição de Luiz Flávio Gomes, "Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In EL TASSE, Adel et. al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197). O conjunto probatório produzido sob a garantia do contraditório judicial é harmônico com os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, ambos indicando que os réus traziam consigo os entorpecentes descritos na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sabendo da sua destinação ao tráfico de entorpecentes.

Por outro lado, quanto ao delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, das provas amealhadas ao longo do inquérito e dos depoimentos dos policiais e demais provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório, não há como inferir, com a necessária certeza, o vínculo de estabilidade e permanência necessários a respaldar uma segura condenação, não havendo prova de materialidade da existência de associação criminosa.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado que "A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa." (HC 462.888/RJ, Rel.Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe05/11/2018).

E não é outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O verbo núcleo do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado, em um concurso de agentes. Doutrina e jurisprudência. 2. No particular, concluiu-se pela condenação tão somente em razão da convergência ocasional de vontades para a prática do crime de tráfico. Noutras palavras, não se separou a vontade de se associar da vontade necessária para a prática do crime pretendido. 3. "Não é questão de prova saber-se da tipicidade de determinado fato, cuja veracidade não se discute, mas se admite como afirmado na sentença: cuida-se de simples qualificação jurídica de fato, operação à qual sempre se prestou o habeas corpus" (RHC 75236; Relator (a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Segunda Turma, DJ1º/8/1997). 4. Habeas corpus concedido para absolver a paciente do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), com extensão da ordem à corré. (STF - HC: 124164 AC, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 11/11/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-230 DIVULG21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014).

Nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: Apelação criminal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Recursos da Defesa e do Ministério Público. Condenação confirmada, quanto ao primeiro crime, dado o firme conjunto probatório. Valorização do depoimento policial. Associação afastada, ante a ausência de comprovação de sua estabilidade e permanência. Absolvição quanto a tal delito. Penas reduzidas, com abrandamento do regime prisional. Parcial provimento ao apelo da defesa e não provimento ao recurso ministerial. (TJSP; Apelação Criminal 0000021- 93.2019.8.26.0556; Relator (a):

Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2021; Data de Registro: 19/02/2021); REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de ilegalidade na atuação dos guardas civis municipais. Conduta dos agentes públicos permitida, a teor do artigo 301, do Código de Processo Penal. Pretensão de reconhecimento de nulidade por violação de domicílio. Inocorrência. Requerente que foi abordado com droga em frente ao imóvel. Ingresso na residência autorizado pela corré, que era esposa do peticionário. Ausência de provas no que tange à estabilidade e permanência da suposta associação. Absolvição que se impõe quanto ao delito disposto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06. Pena imposta pela prática do crime de tráfico de drogas corretamente fixada. Regime inicial fechado mantido em face do quantum da pena e da reincidência do requerente. Pedido revisional parcialmente deferido, com extensão dos efeitos da absolvição pelo rime de associação ao tráfico de drogas à corré. (TJSP; Revisão Criminal 0010326-58.2019.8.26.0000; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro de Americana - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/02/2021; Data de Registro: 10/02/2021).

Destarte, seguindo tais orientações jurisprudenciais, compreendo que as provas coligidas não se mostraram capazes de demonstrar elo estável e permanente entre os réus. Ressalto que o breve acompanhamento descrito pelos policiais não pode ser considerado meio hábil a comprovar a permanência e estabilidade que o tipo penal em comento demanda. Assim, apesar da existência de indícios, tais indícios não se tornaram em provas suficientes para sustentar uma condenação, sendo, portanto, a absolvição medida que se impõe.

No tocante ao delito de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), é de rigor a absolvição. Isto porque, a Lei nº 11.343/06 prevê causa especial de aumento de pena caso o crime de tráfico envolva ou atinja criança ou adolescente, conforme previsão do artigo 40, inciso VI, do referido diploma legal, in verbis: "Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...) VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação";

Assim, para evitar a ocorrência de bis in idem, de rigor a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista na Lei de Drogas e a absolvição do delito previsto no artigo 244-B do ECA, em homenagem ao princípio da especialidade. Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR. PLEITO DE CONDENAÇÃO CONCOMITANTE COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Configura bis in idem a condenação conjunta do tráfico de drogas majorado pela participação de menor com o crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.716.826/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018.); Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes praticado na companhia de adolescente (art. 33, "caput", cc. art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), em concurso material - Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da absorção do delito de corrupção de menores pelo de tráfico de drogas - Autoria e materialidade bem demonstradas, com a venda de entorpecentes a um usuário tendo sido presenciada pelos policiais militares responsáveis pela prisão - Sentenciado que trazia consigo e guardava, na companhia do adolescente mencionado na denúncia, 54 porções de "cocaína" com peso líquido total de 59,23g - Reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei de Drogas e do delito previsto no ECA que caracteriza inegável "bis in idem" - Majorante prevista na Lei Antidrogas que é "norma especial" em relação à corrupção de menores, por se referir à prática, na companhia do(s) menor(es), de delito específico - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Prisão cautelar do

réu que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade de nºs 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso parcialmente provido para absolver o sentenciado quanto à acusação de prática do delito do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, mantida a condenação pelo delito do art. 33, "caput", cc. art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06. (TJSP; Apelação Criminal 1500510-12.2019.8.26.0603; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/05/2021; Data de Registro: 25/05/2021, destaquei). Por outro lado, a causa especial de aumento de pena do crime de tráfico envolvendo adolescente, conforme previsão do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 restou devidamente configurada, vez que a própria adolescente H.A.G indicou aos policiais que a pessoa responsável por lhe fornecer os entorpecentes era o acusado ADAURI. Assim, tendo em vista a prova produzida e os argumentos apresentados, é de rigor a parcial procedência da ação nos termos acima delineados. Apurada a responsabilidade, passo a fixar a pena atendendo ao método trifásico da dosimetria.

Réu ADAURI DA SILVA JUNIOR:

Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, verifico que o acusado guardava vultosa quantidade de entorpecentes, com grande variedade, dentre as quais havia crack e cocaína, entorpecentes conhecidos pelo alto poder viciante e vulnerante, razão pela qual elevo a pena-base em 1/5. Assim, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão, além de 600 dias-multa.

Na segunda fase compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (fls. 77/79), mantendo-se a pena fixada na fase anterior.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso, VI da Lei nº 11.343/06, logo, aumento a pena em 1/6, resultando em 07 anos de reclusão, além de 700 dias-multa. Tendo em vista que o réu é reincidente em crime doloso, compreendo que não estão preenchidos os requisitos do § 4.º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Ré ALESSANDRA APARECIDA DIAS:

Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, verifico que a ré possui Maus antecedentes (fls. 295/297). Trata-se de condenação por crime semelhante, merecendo maior reprovação, razão pela qual elevo a pena mínima em 1/5. Ademais, verifico que a acusada guardava vultosa quantidade de entorpecentes, com grande variedade, dentre as quais havia crack e cocaína, entorpecentes conhecidos pelo alto poder viciante e vulnerante, devendo ser somado mais 1/5 à fração de aumento. Assim, elevo a pena em um total de 2/5 nesta fase, e fixo a pena-base em 07 anos de reclusão, além de 700 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes, mantendo-se a pena fixada na fase anterior.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso, VI da Lei nº 11.343/06, logo, aumento a pena em 1/6, resultando em 08 anos e 02 meses de reclusão, além de 816 dias-multa. Tendo em vista que a ré possui Maus antecedentes, compreendo que não estão preenchidos os requisitos do § 4.º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Partindo de tais premissas, anoto que o início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, deverá se dar em regime inicial FECHADO para ambos os acusados, considerando o montante de pena imposta associado à reincidência, no caso do réu ADAURI, e aos Maus antecedentes, no caso da ré ALESSANDRA. Além disso, a gravidade em concreto do delito praticado, consubstanciado na grande quantidade e variedade de entorpecentes de alto poder lesivo, com envolvimento de adolescente, também é fundamento para a aplicação do regime mais gravoso.

Ante a ausência de informações da capacidade econômica dos acusados, fixo a valor de cada dia multa no mínimo legal.

Para a aplicação da retratação penal do art. 387, §2º, CPP, necessário o

preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, inexistente prova do requisito subjetivo.

Ausentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para os acusados.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR:

I. o réu ADAURI DA SILVA JUNIOR à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial FECHADO, além de 700 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; e

II. a ré ALESSANDRA APARECIDA DIAS à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial FECHADO além de 816 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, ABSOLVO os réus da prática dos delitos previstos no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de manutenção da prisão cautelar, deve ser afastada a possibilidade de recurso em liberdade.

Assevere-se, nesse ponto, que o Supremo Tribunal Federal sufragou o entendimento de que "é pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (HC 89.824/MS, rel. Min. Carlos Britto, DJ 28-08-08). Nos mesmos moldes vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que assenta que "é incompatível com a realidade processual manter o réu preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade. Precedentes." (HC 289.217/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 21/05/2014).

Ademais, observa-se que a ré ALESSANDRA APARECIDA DIAS violou, por duas vezes (fls. 328/332), a prisão domiciliar que lhe foi concedida, não tendo a defesa apresentado qualquer justificativa em sua manifestação. Assim, é de rigor o restabelecimento da prisão preventiva.

Destarte, NEGOU o direito de recorrer em liberdade aos réus, bem como RESTABELEÇO a prisão preventiva da ré ALESSANDRA APARECIDA DIAS.

Recomende-se o réu ADAURI DA SILVA JUNIOR ao estabelecimento prisional em que se encontrar recolhido e expeça-se, imediatamente, a respectiva Guia de Recolhimento Provisória.

Expeça-se mandado de prisão em desfavor de ALESSANDRA APARECIDA DIAS, imediatamente.

DECRETO o perdimento dos objetos e valores apreendidos em favor da União.

Custas ex lege.

Após o trânsito em julgado:

I) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB/88, bem como IIRGD.

II) Comunique-se o Juízo da Execução, para aditamento da Guia de Recolhimento, encaminhando-se as peças necessárias.

III) Tendo em vista a aplicação de pena de multa, feito eventual abatimento em caso de fiança recolhida (art. 479 das NSCGJ), expeça-se certidão de sentença do valor remanescente, de acordo com o modelo próprio do Sistema SAJ - Categoria 2 (Certidões), Modelo 505791, e abra-se vista ao Ministério Público, arquivando-se após os autos, com as anotações de praxe.

IV) oficie-se à autoridade policial para incineração da contraprova.

V) Oficie-se para que o banco depositário providencie a transferência do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas - Funad.

VI) Comunique-se o Sr. Escrivão Judicial, responsável pela Seção de Depósito e Guarda de Objetos, acerca do perdimento dos objetos apreendidos.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe.

P.I.C.

Caraguatatuba, 09 de novembro de 2022.

JÚLIO DA SILVA BRANCHINI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA